

1501270-65.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... seria conhecido como um "ponto de tráfico" não é presunção absoluta do envolvimento do réu na prática do crime, eis que, nesses lugares, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários das substâncias. E o vídeo juntado aos autos também não demonstra, efetivamente, a vinculação do réu ao tráfico, eis que se trata de uma gravação efetuada a uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501270-65.2022.8.26.0599 - Controle nº 2022/001113

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2229130/2022 - GOE-DEIC-DEINTER 9

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS LEANDRO RAFAEL

Réu Preso

Aos 13 de dezembro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dra. FERNANDA GUIMARÃES ROLIM BERRETA - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: CARLOS LEANDRO RAFAEL - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC ANDRE AUGUSTO PIRES - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO BARHUN - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos das testemunhas PC MARCIO LUIZ TEIXEIRA DE CARVALHO BARHUN e PC ANDRE AUGUSTO PIRES.

Após, o réu CARLOS LEANDRO RAFAEL foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ. A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pela Dra. Promotora de Justiça foi dito o seguinte: "CARLOS LEANDRO RAFAEL, já qualificado nos autos em epígrafe, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelas condutas delituosas descritas na exordial acusatória. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado (fls. 180/181), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 186/187), sendo a denúncia recebida (fls. 188/190). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu, por fim, interrogado. Em síntese, o necessário. Passa-se à manifestação. A prova produzida impõe a procedência da ação penal. A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 47), pela fotografia (fls. 46), pelo laudo de constatação preliminar (fls. 50/52) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 118/120). A autoria do crime de tráfico de drogas descrita na denúncia restou também suficientemente comprovada. O policial civil Márcio Luiz Teixeira De Camargo Barhun, confirmando suas declarações prestadas na fase investigativa, narrou que, na data dos fatos, realizavam investigação focando o comércio ilícito de entorpecentes, no bairro Jardim Oriente. Esclareceu que estava realizando observação discreta no interior de viatura descaracterizada e, durante a observação, constatou a presença do réu, que por mais de uma vez foi até um saco de lixo, de lá pegava algo, e entregava para pessoas que o procuravam. Disse que viu essa conduta do acusado por no mínimo duas vezes, que entregou algo que pegou no lixo para motoristas que o abordaram. Diante de tal circunstância, acionou seus colegas de serviço que estavam com viatura caracterizada nas proximidades do local, informando características físicas e o local onde estava ocultada a droga. Sabe que durante revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$35,00 (trinta e cinco reais em cédulas diversas) e, no local onde presenciou o réu escondendo algo, foram encontrados foram encontrados 10 (dez) eppendorfs de cocaína. Por fim, disse que realizou filmagens da conduta do acusado. No mesmo sentido foram as palavras do policial civil André Augusto Pires, que confirmou que foi acionado por seu colega Bahrum, que narrou as características do indivíduos que vira em atitude típica de trafico, bem como o local onde escondia as drogas. Abordaram-no e em poder do acusado encontraram a quantia de 35,00 em notas trocadas, e, no lixo onde o acusado pegava e escondia algo, encontraram os entorpecentes apreendidos. Por fim, interrogado, o réu narrou que havia recebido dinheiro de um trabalho de uma senhora e, na véspera do dia dos fatos, usou drogas com um travesti com quem mantém relacionamento e, no dia dos fatos, foi comprar mais drogas para uso dos dois, tendo seu companheiro retirado do banco a quantia de cento e trinta reais. Comprou em um bar dez capsulas de pó e pretendia comprar seis porções de crack, mas não tinha no bar naquele momento. Disse que saiu do bar e foi ao encontro de seu companheiro. Quando virou a esquina, encontrou os policiais civis, sendo que trabalha como informante dos mesmos, e eles perguntaram "se tinha alguém lá", tendo confirmado. Disse que então guardou no saco de lixo as dez porções de cocaína que tinha comprado, e foi então até a praça tomar pinga, enquanto esperava "sua travesti" vir busca-lo. Ela veio com um carro prata, manteve contato com o motorista, que era seu companheiro, e então resolveu esperar o crack que queria comprar chegar. Voltou para a praça e depois foi abordado pelos policiais, que lhe mostraram o vídeo que fizeram, vídeo que de fato aparece guardando suas porções de cocaína no lixo e mantendo contato com "sua travesti" no carro prata. Indagado sobre as contradições entre essa sua versão e a versão apresentada na fase inquisitiva, o acusado não conseguiu justificar-se a contento, tendo ao final alegado que o que falou na fase policial não aconteceu. Ora, sua versão não tem como prevalecer, eis que restou totalmente isolada no álbum probatório. De fato, tem-se que, de fato, na fase policial o acusado apresentou versão totalmente diversa, tendo ele na ocasião alegado que na ocasião dos fatos alguns indivíduos em veículos lhe pediram cigarro e de pronto dava um cigarro para estas pessoas. Disse que quando foi visto mexendo embaixo de um sacode lixo plástico, estava procurando latinhas para vender e que as drogas localizadas estavam abandonadas próximas da calçada, desconhecendo de quem sejam as porções localizadas. Tais contradições, por si só, demonstram claramente a falácia de suas palavras. De outra banda insta ressaltar que os policiais civis ouvidos

foram uníssonos e coesos ao afirmar que o acusado foi flagrado em típica conduta de tráfico, atendendo mais de um motorista, entregando-lhes algo e deles recebendo algo, bem como mexeu, por mais de uma vez, o saco de lixo onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais são plenamente válidos como meio de prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu a Quinta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça nos termos do voto do Relator Ministro Ribeiro Dantas no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.096.763/T0, julgado em 14/06/2022 e publicado no DJe de 20/06/2022, do qual se extrai o seguinte trecho: Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ainda nesse sentido: Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório. (STJ – HC n. 395.325/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Julgado em 18/05/2017, DJe de 25/05/2017).

(Grifei) Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Quanto à aplicação da reprimenda, tem-se que o réu detém maus antecedentes (autos nº 0011033-80.2009.8.26.0451 – fls. 155), razão pela qual a pena base deve ser fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, constatei que o réu é reincidente (autos nº 0000341-82.2017.8.26.0599 – fls. 153; 0000516-13.2016.8.26.0599 – fls. 153/154; 0010271-20.2016.8.26.0451 – fls. 154/155; 0037664-66.2006.8.26.0451 – fls. 156/157; 1542557-06.2018.8.26.0451 – fls. 158), o que enseja o agravamento da pena. Na terceira fase, ante a reincidência do acusado, inaplicável o art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, consistente em R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006. Diante do exposto, o Ministério Público requer e aguarda a procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da exordial".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma como descrito na exordial. Encerrada a instrução probatória nesta data, a Defensoria Pública entende que as provas levadas aos autos não autorizam a prolação de um édito desfavorável ao denunciado, razão pela qual deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. Isso porque, como se sabe, a Constituição Federal garante a presunção de inocência, de tal sorte que se faz necessário um conjunto probatório robusto e harmônico para que se autorize a prolação de um decreto condenatório. Nesta data, a testemunha Marcio, Policial Civil, declarou que estava fazendo uma investigação em viatura descaracterizada, em um ponto de tráfico. Visualizou o réu fazendo vendas para veículos, pegando objetos com a pessoa do automóvel, indo até um saco de lixo, pegando a droga que estava embaixo do saco e entregando para os ocupantes do automóvel. Diante disso, começou a filmar a ação e acionou os outros policiais, que abordaram o acusado. Com ele, encontraram a quantia de R\$ 35,00. E as drogas foram encontradas no local que ele estava mexendo. Não conhecia o réu antes dos fatos. A testemunha Andre, Policial Civil, declarou que foi contatado pelo seu parceiro, o qual informou que uma pessoa estaria vendendo drogas no bairro Jardim Oriente. Ele disse as características da pessoa e o local onde as drogas estavam. Efetuaram a abordagem do réu e ele negou que estava vendendo drogas. Porém, no local informado por seu parceiro, encontraram 10 porções de cocaína. E com o réu encontraram R\$ 35,00 em notas diversas. Não conhecia o réu. O réu, em interrogatório, declarou que, quando estava preso, iniciou um relacionamento com uma travesti. Quando saiu da prisão, começou a morar na rua. No domingo, teria recolhido reciclagem e recebeu R\$ 15,00 pelo serviço. Usou o dinheiro para comprar 02 porções de crack para seu consumo pessoal. Costuma dormir em uma construção abandonada. No outro dia de manhã, a travesti com quem era casado foi procurá-lo e

perguntou o motivo pelo qual não foi até a casa dela. Ela pediu que entrasse no carro dela e foram para um hotel no centro. No dia seguinte (domingo), usaram quatro porções de cocaína. Na segunda-feira, as drogas acabaram, por isso saíram para comprar mais drogas. A travesti retirou dinheiro em um supermercado (cerca de R\$ 130,00) e entregou a quantia ao réu. Foi até um bar onde vendem drogas e pediu para o traficante 10 porções de cocaína e 06 porções de crack. O traficante entregou apenas a cocaína e disse que o crack tinha acabado. Ele mandou que o réu esperasse. Disse a ele que não poderia esperar, pois estava assinando carteirinha e foi embora. Quando saiu do ponto, uma viatura da Polícia passou e perguntou ao réu se tinha algum traficante no local, pois costuma atuar como informante dos Policiais. Atravessou a rua e escondeu as drogas em um saco de lixo, esperando a travesti voltar com o carro (ela tinha ido embora por conta da viatura). Ficou na praça com alguns moradores de rua. A travesti voltou e perguntou se já tinha comprado as drogas. Disse a ela que não, pois estava esperando o crack chegar. Ela foi embora e ficou esperando na praça. Os Policiais, então, chegaram e mandaram o réu sentar. Disseram que era uma abordagem de rotina e perguntaram se o réu vendia drogas. Eles disseram que tinha uma filmagem dele vendendo, mas era a filmagem dele conversando com a travesti e escondendo as drogas que tinha comprado para seu consumo. Questionado sobre a versão na Delegacia, disse que a travesti também pediu para comprar cigarros para ela. Os Policiais disseram que, se falasse para o Delegado que era traficante, eles apagariam a filmagem, mas se negou a dizer isso. Por isso, foi levado à Delegacia. No local, o Policial Celso até falou que ele era usuário de drogas, não era traficante. E os Policiais da ROMU o ajudam com algumas porções de drogas quando fazem prisões. Não tem vínculos com facção criminosa, eles não entregam drogas para usuários venderem. Portanto, Excelência, o acusado nega a prática dos fatos. Sua negativa deve ser considerada um elemento probatório, afastando-se qualquer juízo preconceituoso que se tenha contra ela, sobretudo porque não refutada pelas demais provas dos autos. Isso porque, as provas produzidas pela acusação restringem-se, apenas, às palavras dos Policiais responsáveis pela prisão do acusado, as quais, todavia, devem ser recebidas com reservas. Com efeito, mister destacar, neste ponto, que a Defensoria Pública não pretende desqualificar a nobreza ou a honestidade de uma instituição responsável pela segurança pública do Estado ou negar a força probatória dos depoimentos dos agentes, embora seja inegável que eles, na grande maioria das vezes, ratifiquem em Juízo a versão apresentada quando da realização da prisão, inclusive como forma de convalidar o ato e seus respectivos efeitos. Sustenta a Defensoria Pública, na realidade, que os depoimentos dos agentes, sem amparo de outras provas que estejam ao alcance dos órgãos responsáveis pela persecução penal, não podem servir de fundamento para a prolação de uma sentença condenatória, sob pena de se atribuir à referida prova caráter quase absoluto no processo penal, fragilizando as garantias do devido processo legal e da ampla defesa, bem como inviabilizando a busca da verdade processual. Aliás, em se tratando de delitos de drogas, o E. Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de não admitir as palavras de Policiais ou outros agentes de segurança como fundamento para uma condenação: "Assim, o que se verifica, é que a condenação foi amparada exclusivamente nas declarações policiais, o que se revela insuficiente. É que seus testemunhos tem qualificação e natureza diversas de qualquer outro. São relatos de agentes policiais, ou seja, a longa manus do próprio aparelho repressor, de modo que as teorizações jurídicas processuais de âmbito criminal não podem ignorar a realidade fática. O policial é o agente operacional da repressão e não depõe com a imparcialidade das demais testemunhas, ainda que de modo inconsciente. Sua visão sobre os fatos, o seu entendimento sobre as circunstâncias que apurou, são do próprio sistema repressor, dos quais o garantismo constitucional do devido processo legal objetiva proteger." (TJSP - 7ª Câmara Criminal - Ap. 0020153-57.2006.8.26.0224 -- Rel. Francisco Menin - j. 03/02/11 - grifado). Inclusive, no caso em pauta, verifica-se que, a despeito das declarações dos Policiais e da "movimentação suspeita" supostamente visualizada, não é possível afirmar, com certeza, que as condutas se tratavam efetivamente de um ato de venda de drogas, eis que os supostos compradores não foram apresentados na Delegacia de Polícia e não existem outras testemunhas

presenciais dos fatos. Além disso, as substâncias não estavam sob a posse direta do acusado, eis que seu encontro ocorreu em um local aberto, de livre acesso a qualquer indivíduo. Ressalta-se, ainda, que a mera afirmação de que o endereço da abordagem seria conhecido como um “ponto de tráfico” não é presunção absoluta do envolvimento do réu na prática do crime, eis que, nesses lugares, circulam tanto indivíduos que se dedicam ao comércio de drogas quanto usuários das substâncias. E o vídeo juntado aos autos também não demonstra, efetivamente, a vinculação do réu ao tráfico, eis que se trata de uma gravação efetuada a uma grande distância e o contato do acusado com o veículo foi muito breve, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que aquilo seria um ato de venda de drogas. Portanto, diante das provas produzidas, a absolvição do réu é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Entretanto, na hipótese deste E. Juízo afastar o pleito absolutório, requer-se, ao menos, diante das declarações do acusado em seu interrogatório, a DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. Isso porque, com a devida vênia, há de se reconhecer que não há nos autos indícios de que o acusado fosse comercializar as drogas apreendidas, sendo que, reitere-se, não foi verificado qualquer ato efetivo de mercancia dos entorpecentes. Assim, no máximo, o réu poderia ser responsabilizado por portar drogas para fins de consumo pessoal, pois não foi demonstrado cabalmente o intuito lucrativo, não bastando a simples apreensão do entorpecente em poder do acusado para se justificar uma condenação por tráfico. Vale observar, ainda, que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas em poder do réu nada diz quanto à sua destinação, eis que a quantidade necessária para a satisfação de um usuário é completamente variável. Para a configuração do crime de tráfico, não basta a simples apreensão da droga, sendo imprescindível a aferição de prova cabal da finalidade de mercancia dos entorpecentes por parte do réu, o que não foi o caso. Todavia, caso mantida a condenação pelo tráfico de drogas, requer-se, então, a APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, MESMO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. Isso porque, ainda que considerado reincidente, vale lembrar que a Lei de Drogas, ao fixar como pena mínima, para o delito de tráfico, cinco anos de reclusão, prevendo, ainda, a causa de diminuição de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) para primários, acaba por valorizar, em demasia, o critério da reincidência. Desde, portanto, que presentes os outros requisitos para a aplicação da causa de diminuição (ou seja, não havendo elementos probatórios de que o réu se dedique ao crime, praticando-o com contumácia, e sem provas de que ele integre organização criminoso), é de se considerar que o peso atribuído à reincidência é superdimensionado em relação ao apenamento do agente primário, ofendendo, assim, o princípio da proporcionalidade, implícito no ordenamento constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF). A aplicação da pena ao réu primário, presentes os demais requisitos legais, ensejaria a redução no patamar de 2/3, implicando a sanção de um ano e oito meses de reclusão. Ao réu reincidente, o mesmo fato representaria, pela ausência de aplicação da causa de diminuição, uma pena de 5 (cinco) anos. O peso da reincidência, portanto, é claramente desproporcional, pois o valor do fato praticado é de aproximadamente 1/3 (um terço) da pena, sendo 2/3 (dois terços) aplicados em função da reincidência. Essa desproporção também é inconstitucional porque atribui, para a dosagem da pena, valor maior aos fatos pretéritos do que à própria acusação em questão. Aceitar-se como válida a ampliação ao infinito do peso da reincidência implica a aplicação do direito penal do autor e não do fato – punição fundada preponderantemente em quem o agente é (ou seja, em face de seus antecedentes) e não em função do ato por ele praticado. Como afirma Muñoz Conde: “A distinção entre Direito Penal do ato e Direito Penal do autor não é só uma questão sistemática, mas, também, e fundamentalmente, política e ideológica. Só o Direito Penal baseado no ato cometido pode ser controlado e limitado democraticamente (...) o Direito Penal do autor não permite limitar o poder punitivo do Estado e favorece sua concepção totalitária” (Teoria Geral do Delito – SAFE, p. 09/10). O direito penal do autor não se coaduna com o Estado Democrático de Direito e por isso suas impressões devem ser descartadas, inclusive pelo Juiz. No mesmo sentido: “O direito penal de autor não

encontra guarida em nenhum sistema penal fincado no Estado de Direito, comprometido, que é, com a dignidade da pessoa humana e com a garantia de seus direitos fundamentais, e, sobretudo, em nosso ordenamento, onde a presunção vigente é, ao reverso do que se propugna com a referência a tal condenação, a de inocência." (Min. Cezar Peluso em Voto Visto no RHC 81.057-8-SP). Por fim, nem se diga da impropriedade de se afastar uma regra legal (proibição da redução ao reincidente) em face de um princípio não explícito. Como afirma Fábio Konder Comparato, apesar de seu alto grau de abstração, os princípios são normas jurídicas e não simples recomendações programáticas ou exortações políticas. Mais ainda: trata-se de normas jurídicas de eficácia plena e imediata, a dispensar a intermediação de regras concretizadoras. Provocado ou não pelas partes, o juiz está sempre autorizado a aplicar diretamente um princípio ao caso trazido ao seu julgamento, por força do disposto no §1º do art. 5º, da Constituição ("O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos", in Direitos Humanos - Visões Contemporâneas, edição de Associação Juizes para a Democracia, 2001). Por fim, caso não sejam acolhidas as teses anteriores, a defesa requer, no tocante à dosimetria da pena: (i) a fixação da pena-base no patamar mínimo previsto na lei, ressaltando-se a pouca quantidade e diversidade de entorpecentes apreendida, sendo que as demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP são favoráveis ao acusado, ressaltando-se que a sua vida pregressa deve ser valorada somente na segunda fase, a fim de se evitar eventual bis in idem com eventual agravante da reincidência; (ii) a incidência, na terceira fase da dosimetria, do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como sustentado; (iii) seja fixado o regime menos gravoso do que o fechado para início do cumprimento da pena, considerando o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, que impunha, obrigatoriamente, o início do cumprimento da pena no regime fechado, em relação aos crimes hediondos e os a ele equiparados (STF - Pleno - HC nº 111.840/ES - rel. Min. Dias Toffoli), em atenção, ainda às súmulas nº 718 e 719, do E. STF e das súmulas nºs 269 e 440 do E. STJ e, ainda, em razão do disposto no art. 387, § 2º, do CPP; (iv) seja concedida ao acusado a possibilidade de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que autorize, neste momento processual, a manutenção de sua prisão preventiva".

Então, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

CARLOS LEANDRO RAFAEL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 22 de agosto de 2022, por volta das 11h20min, Rua Paschoal Barsottini, nº 255, Bairro Residencial Serra Verde, nesta cidade e comarca de Piracicaba, guardava e mantinha em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros 10 (dez) eppendorfs de cocaína em pó, pesando aproximadamente 16,64g (dezesesseis gramas e sessenta e quatro decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que policiais civis realizavam investigação focada no comércio ilícito de entorpecentes pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de drogas, através de viaturas caracterizadas e descaracterizadas. Durante o monitoramento, um agente da lei, que estava na viatura descaracterizada, avistou CARLOS em típica conduta de tráfico de drogas, pois, por duas vezes, manteve contato com dois carros, recebendo e entregando algo em troca dos motoristas. O policial ainda avistou o momento em que o réu se dirigiu até uma calçada, abaixou-se, retirou um "saquinho" que estava escondido sob um saco de lixo e o escondeu debaixo de outro. Diante dos fatos, o policial efetuou contato telefônico e passou as características pessoais do indivíduo para os demais agentes que se encontravam nas proximidades do local dos fatos, os quais se dirigiram ao local, avistaram o réu e o abordaram devido à fundada suspeita. Os agentes públicos, em revista pessoal, encontraram na posse de CARLOS, R\$ 35,00 em espécie e, sob o saco de lixo onde havia ele guardado algo, encontraram 10 eppendorfs de cocaína. O réu foi notificado nos termos do art. 55 da Lei 11.343/06 (fls. 181) e apresentou

defesa preliminar (fls. 186/187), seguindo-se a decisão que recebeu a denúncia (fls. 188/190).

Designada audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. Após, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do réu.

A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 47, pelas fotografias de fls. 46 e 48 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 121/123, que trouxe resultado positivo para cocaína. A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu negou a prática do delito. Disse que, na data dos fatos, estava na praça do Jardim Oriente, próximo à Rua Paschoal Barsottini, quando alguns indivíduos em veículos lhe pediram cigarro e, de pronto, deu o cigarro para eles. Disse que era catador de recicláveis e estava mexendo embaixo de um saco de lixo plástico, procurando latinhas para vender, quando foi visto pelos policiais. Asseverou que não estava traficando drogas. Disse que as drogas localizadas estavam abandonadas próximo à calçada e que desconhecia o proprietário delas. Disse que o dinheiro apreendido na sua posse era fruto da venda de recicláveis (fls. 06).

Em juízo, voltou a negar a prática do crime. Mas inovou. Declarou que estave na colônia penal e foi casado com uma travesti, durante um ano e oito meses. Disse que, quando saiu, ficou morando na rua. No domingo, usou uma carriola para fazer um serviço para uma senhora e recebeu R\$ 15,00. No dia seguinte, saiu da construção onde dormia e lhe disseram que uma senhora estava chamando por ele. Afirmou que foi ver o que se tratava e constatou que era sua travesti. Então, ela lhe perguntou porque ele não tinha procurado por ela quando saiu, ao que respondeu que tinha perdido o telefone dela. Asseverou que entrou no carro com ela e foram para um hotel. Disse que ela tinha quatro porções de pó e usaram. Após, ela falou para cheirarem mais, mas ele não tinha dinheiro. Sustentou que sua travesti falou que pararia num supermercado e retiraria dinheiro. Então, foram ao supermercado e ela falou que tiraria cem reais para comprar pó, tendo ele pedido para ela pegar cento e trinta, pois queria comprar seis pedras também. Na sequência, ela lhe entregou uma nota de cem e três de dez, como que seguiu para o bar onde vendem drogas.

Afirmou que pediu dez cápsulas de pó e seis pedras de crack, tendo o rapaz lhe entregado só o pó e falado que não tinha mais crack e era para ele esperar. Alegou que estava de carteirinha e não podia esperar. Disse que saiu do local, virou a esquina e se deparou com os policiais militares Juliana e Fabiano, que não o pararam, pois é informante deles. Sustentou que eles perguntaram se tinha alguém vendendo, ao que respondeu que sim. Disse que eles fizeram o enquadro, enquanto ele colocou os pinos embaixo de um saco preto. Declarou que a travesti viu a viatura e saiu, pois também estava de carteirinha. Após, parou um Gol prata e ela lhe chamou, perguntando se ele já tinha comprado, ao que respondeu que não, porque queria esperar o "crack". Aduziu que a sua travesti lhe disse que andaria mais um pouco e voltaria a passar ali para pegá-lo. Declarou que ficou na praça, tomou pinga e ficou aguardando, quando veio a ser abordado pelos policiais, que lhe perguntaram se vendia droga e falaram que tinha uma filmagem dele vendendo, mas, na filmagem, só aparecia ele guardando a droga embaixo de um saco e conversando com a travesti. A duplicidade de versões retira a credibilidade da palavra do réu, posto que essa situação não é compatível com a de quem pode explicar adequadamente os fatos. A cada momento em que deu sua versão dos fatos, contou uma história diferente, o que reflete negativamente em sua situação, pois caso fosse realmente inocente, não teria necessidade de ofertar versões diferentes a cada vez que fosse ouvido (cf. Apelação 0004859-04.2005.8.26.0481, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavaleiro, j. 12.06.12).

De todo modo, a versão apresentada pelo réu foi infirmada pela prova produzida. Com efeito, o policial civil Marcio relatou que fazia investigação, sozinho, em

viatura descaracterizada, no Jardim Oriente, já conhecido como ponto de tráfico. Disse que observou um indivíduo possivelmente fazendo venda para ocupantes de veículos e notou que ele pegava algo na calçada, retirava debaixo de um saco, fazia a entrega e voltava a guardar. Asseverou que começou a filmar e o réu chegou bem próximo dele. Atestou que passou a informação para os demais policiais, que fizeram a abordagem, encontrando 35 reais em notas diversas com o réu e a droga no local que tinha informado a eles.

O policial civil André narrou que, no dia dos fatos, foi contatado pelo policial Marcio, que informou que uma pessoa estava comercializando entorpecentes no Jardim Oriente. Ele passou as características da pessoa e local onde estaria sendo guardada a droga. Disse que abordaram o indivíduo, que se identificou como sendo Carlos e negou a prática do crime. Então, foram ao local indicado pelo policial Marcio e acharam dez porções e cocaína.

É de se asseverar que o simples fato de as testemunhas de acusação serem policiais civis não é o bastante para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas. Não estando impedidos, seus depoimentos serão considerados como o de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tinham para falsear a verdade, a não serem cumpridores de seus deveres funcionais.

E "como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial" (RJTJESP 125/263). Nesse mesmo sentido: RT 591/313, 612/316 e 654/278.

A prova acusatória consistente em depoimentos de policiais é tão válida quanto outra qualquer, desde que tais testemunhos sejam insuspeitos, sérios e coerentes. Acrescento que a presunção de imparcialidade, retidão e lisura deve ser em favor da autoridade pública, que age no estrito cumprimento do dever legal (cf. RT 738/665). E o relato dos policiais está amparado pelo vídeo cujo link está encartado a fls. 166.

Enfim, o fato de os policiais terem flagrado e, inclusive, fotografado (fls. 46), o acusado praticando atividade típica da traficância, vindo a apreender R\$ 35,00 em poder dele e 10 eppendorfs de cocaína sob o saco de lixo que ele acessou, conduz à certeza quanto a autoria e a traficância.

Consigno que a quantidade de entorpecentes apreendida e a forma como estavam acondicionados, aliados ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, e à flagrância de atos típicos de traficância, deixam mesmo evidente que o entorpecente se destinava ao comércio ilícito.

Sobre a viabilidade desses elementos demonstrarem a destinação comercial dos entorpecentes, cito os seguintes precedentes:

"Apelação. TRÁFICO DE DROGAS. Conjunto probatório firme e coeso para manter a responsabilização do réu, notadamente pelos relatos dos policiais e a existência de denúncias anônimas apontando o réu como sendo traficante de drogas. Quantidade e forma de acondicionamento que demonstram a destinação das drogas para a mercancia. Penas. Redução. Possibilidade - Regime prisional incensurável PARCIAL PROVIMENTO AO APELO." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0004053-31.2010.8.26.0242, 10ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Rachid Vaz de Almeida, j. 16/02/2012, v.u.).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Inconformismo defensivo. - Materialidade e autoria comprovadas. Relatos dos policiais que encontraram drogas em posse do réu - Quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes que não deixam dúvidas da narcotraficância - Condenação mantida - Penas bem dosadas que não comportam reparo. Recurso desprovido." (TJ-SP: Apelação Criminal nº 0038185-16.2007.8.26.0050, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Camilo Léllis, j. 26/04/2012, v.u.).

Consigno, outrossim, que o fato de o acusado ser usuário de entorpecentes, por si só, não infirma a acusação.

Com efeito, é comum que as figuras do usuário e do traficante se encontrem na mesma pessoa, eis que, muitas vezes, o usuário se vale do comércio ilícito de drogas para angariar recursos como meio de sustentar o uso, não ficando, com isso, isento de

responsabilidade pela prática do crime de tráfico.

Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura de traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - RJTJSP, 101/498).

Na mesma esteira o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente" (STJ - REsp 1708569, Rel. Min. Ribeiro Dantas, data de publicação: 06.03.2018).

Impõe-se, portanto, a condenação do réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, observo que o réu ostenta Maus Antecedentes (autos 0037664-66.2006 da 2ª Vara Criminal local - fls. 153/159).

De acordo com o art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência, mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do mesmo código.

Nesse sentido decisão do C. STJ: "EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. DOSIMETRIA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. DECURSO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES.

JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que à luz do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fins de reincidência mas podem ser consideradas como Maus Antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. 2. Considerando que o ordenamento jurídico pátrio adota quanto aos Maus Antecedentes o sistema da perpetuidade, e não da temporariedade, como no caso da reincidência, é de se manter o entendimento pacificado por este Sodalício de que, mesmo ultrapassado o prazo depurador, as condenações anteriores podem ser consideradas como Maus Antecedentes. 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp nº 1.604.407/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 12.08.2016).

E o STF, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos Maus Antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na segunda fase de fixação da pena, anoto que o réu é reincidente (autos 0000341-82.2017 e 0000516-13.2016, ambos da 3ª Vara Criminal local, e autos 0011033-80.2009 da 1ª Vara Criminal local - fls. 153/159 e informações da F.A da VEC a fls. 133/152), razão pela qual aumento a pena em um sexto, resultando seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes.

Inexistem causas de aumento e o acusado não faz jus à redução da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, por ser portador de Maus Antecedentes e reincidente.

Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena, fixo o fechado, em razão da reincidência e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

A fixação do regime inicial fechado está em consonância com diretriz fixada na própria Constituição Federal, que estabeleceu a necessidade de se conferir tratamento mais severo aos casos de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 5º,

inciso XLIII).

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causa à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire o infrator do convívio social, evitando que ele continue a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias.

Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Veda-se, por fim, o direito de apelar em liberdade, valendo observar que o acusado permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça: "Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

Confira-se, ainda, recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a perseguição criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.). Demonstrada a origem ilícita do dinheiro apreendido, declaro seu perdimento.

3. Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu CARLOS LEANDRO RAFAEL, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e oitenta dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime inicial fechado e vedado o direito de apelar em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que está recolhido e, após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido.

Custas na forma da Lei nº 11.608/03.

Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença.

Pelo RÉU foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

Pela DEFESA foi dito que DESEJA RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA do(a) Dr(a). Promotor(a), dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para o MINISTÉRIO PÚBLICO.

2) Recebo o recurso interposto.

3) Intime-se a Defensoria Pública para que apresente razões de apelação.

4) Juntadas as razões, dê-se vista ao MP para contrarrazões de recurso.

5) Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento Provisória.

6) Com as razões e contrarrazões de apelação, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe, salientando que o termo final da prescrição é 12/12/2034.

Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes

Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUIZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]